

중세 이후 특허법제사에 관한 연구

한지영

To cite this article : 한지영 (2008) 중세 이후 특허법제사에 관한 연구, 산업재산권, 25, 1-28

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

중세 이후 특허법제사에 관한 연구*

한 지 영**

◆ 목 차 ◆

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| I. 들어가는 말 | 3. 특허폐지 운동(1850년-1873년) |
| II. 중세 이후 특허보호 | 4. 특허옹호론자의 승리
(1873년-1910년) |
| 1. 세계 최초의 특허법 | |
| 2. 16세기 이후 특허보호 | III. 맺음말 |

I. 들어가는 말

1. 특허(patent)란 형용사로 “공개된(open)”이란 의미이고, 명사로는 “공개장(open letter)”의 축약어로, 라틴어 “*litterae patentes*”¹⁾의 번역어인 “특허장(letters patent)”에서 유래된다. 이때 ‘특허장’이란 어떠한 권리, 특권(privileges), 또는 공인된 권리 같은 공식 문서로, 예컨대 사무관, 군인, 법관 등의 임명 특허, 귀족 특허, 독점 특허, 발명 특허 등이 있다.²⁾ 마찬가지로, 프랑스어로 ‘특허’는 ‘brevet’라고 하는데 ‘brevet’라는 표현 역시 라틴어 ‘*litterae breves*’로부터 유래되었고, 이는 권리 또는 특권을 부여하는 ‘공개된 문서’를 의미한다.

* 이 논문은 2008년도 조선대학교 학술연구비의 지원을 받아 연구되었음.

** 조선대학교 법과대학.

- 1) 라틴어 ‘*patentes*’는 ‘공개’ 또는 ‘개시’라는 의미이다. ‘특허’란 어원상 의미가 ‘공개’에서 비롯된 것은 흥미롭다. 환언하면 특허제도는 신규 발명이 일반 공중에 공개되는 것을 전제로 발명자에게 일정기간 특허라는 배타적 권리를 부여하는 제도인 것이다. 이러한 점에서 특허는 비밀을 전제로 하는 노하우 또는 영업비밀과는 다르다.

- 2) Fritz Machlup, An economic review of the patent system, Washington 1958, p. 1.

2. 발명특허는 저작권, 상표, 상품, 산업디자인 등에 대한 배타적인 권리와 함께 소위 ‘지적재산권(intellectual property)’³⁾에 속하는데, 이러한 ‘지적노동의 산물(products of intellectual labor)’은 일반인으로부터 보호받을 가치가 있다고 할 수 있다. 예컨대, 사회에 유용한 새로운 장치를 발명을 한 경우 발명자는 그 발명을 완성하기 위하여 많은 노력, 시간, 물질적 투자를 하였을 것이므로 보상 차원에서 그에게 일정한 인센티브가 주어져야 할 것이다. 왜냐하면 이러한 인센티브가 주어지지 않는다면 발명자는 계속 땀을 흘려가면서 사회에 유용한 발명을 추가로 완성하려고 하지 않을 것이기 때문이다.⁴⁾

3. 본 논문에서는 발명자에게 일정기간 배타적 권리를 부여하는 대가로 제3자에게 공개할 것을 요구하는 특허제도에 관하여 중세시대 이후 유럽을 중심으로 살펴보고자 한다.

3) ‘지적재산권’이란 용어는 ‘지적소유권’, ‘지식재산권’, ‘무체재산권’ 등으로 표현되기도 하며, 영어 intellectual property를 번역한 것이다. 한편 ‘무체재산권(Immaterialgüterrecht)’은 독일의 Josef Kohler 교수가 최초로 사용한 표현으로, 그는 ‘무체재산권’을 다음과 같이 정의하고 있다: “Das Recht des Erfinders an der Erfindung ist ein Immaterialgüterrecht d. h. ein Recht an einem nicht körperlichen Genussgute der Menschheit, und dieses Recht geht dahin, dass der Berechtigte allein die Befugnis hat, dieses Genussgut nach gewissen Richtungen hin zu benutzen und zu verwerthen.” (번역: 발명에 대한 발명자의 권리는 무체재산권, 즉 모든 인간이 무체물에 대해 향유할 수 있는 재산권으로, 정당한 권리자만이 이러한 재산권을 어떤 경향(gewisse Richtungen)에 따라 사용하고 이용할 수 있는 권한을 가지는 것을 의미한다), Josef Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, 1900, p. 55.

4) 특허의 본질에 관한 이론으로 자연권론(Naturrechtstheorie), 보상이론(Belohnungstheorie), 자극이론(Anspornungstheorie), 공개이론(Offenbarungstheorie)의 4가지를 예시할 수 있다. 상세하게는 Rudolf Krasser, Patentrecht, Verlag C.H.Beck, 5. Aulf., 2004, pp. 34-35. 한편, 1928년에 미국 워싱턴의 국립연구위원회의 실행부는 과학자의 발견에 대한 재산적 권리를 법률로서 보호하는 것은 적절하지 못하다고 주장하기도 하였다, Lawson M. McKenzie, “Scientific Property”, Science, vol. 118 (December 1953), p. 767 이하 참조.

II. 중세 이후 특허보호

1. 세계 최초의 특허법

가. 1474년 베니스 공화국의 특허법

새로운 기술 또는 기능을 발명한 발명자에게 법적 보호를 인정한 것은 15세기부터이다. 특히 발명자에게 일정기간 배타적인 권리를 부여한 세계 최초의 ‘특허법’은 1474년 3월 14일 제정된 이탈리아 베니스 공화국의 특허법이다.⁵⁾ 베니스 공화국 특허법의 원문 및 번역문은 다음과 같다:

El sono in questa Cita, et anche ala zornada, per la grandezza et bontàsoa concorre homeni da diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. Et sel fosse provisto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le havesseno, non podesseno farle, et tuor honor suo, simel homeni exercitariano l’ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sariano de non piccola utilità et beneficio al stado nostro. Pero.

L’andara parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Citàalgun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sara a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provededori de Commun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio,

5) 사실 특허제도는 15세기에 갑자기 출현한 제도가 아니며, 이탈리아의 경우 1421년 Florentine 특허가 있었다. 상세하게는 Giulio Mandich, *Venetian Patents* (1450-1550), *Journal of the Patent Office Society*, 1948, p. 170 이하 참조; 이외에도 W. H. Price, *English Patents of Monopoly* (Boston: Houghton Mifflin, 1906); Authur A. Gomme, *Patents of Invention* (London: Longmans, Green, 936); M. Frumkin, “The Origin of Patents,” *Journal of the Patent Office Society*, vol. 27 (1945), p. 143; Harold G. Fox, *Monopolies and Patents* (Toronto: University of Toronto Press, 1947).

산업재산권 제25호

ad imagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X. Et tamen se algun el fesse, lo auctor et inventor predicto, habia liberta poderlo citar a chadaun officio da questa Cità, dal qual officio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio, subito sia disfacto. Siando però in libertà de la nostra signoria, ad ogni suo piaxter, tuor et usar ne i suo bisogni chadaun di dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condition, che altri cha i auctori non li possi exercitar.

베니스에는 상이한 국적을 가진 사람들이 살고 있는데, 이들은 이탈리아에 신규하고 독창적인 발명을 제공할 수 있다. 우리는 타인에 의해 행해진 신규하고 독창적인 발명을 단순히 보고 난 다음에 이를 무단 복제하는 것을 방지해야 하며, 이를 통해 매우 유익한 창작 활동이 이루어지도록 하여 베니스 공화국의 발전을 도모해야 한다.

‘특허장’에서 본 자문회는 다음과 같이 공포한다:

베니스에 예전에는 없었던 신규하고 창작성있는 장치(nuovo et ingegnoso artificio)를 설계 및 제조한 사람은 누구든지 제3자가 이를 제조 및 복제할 수 없도록 베니스 관청(Provveditori di Comun)에 당해 장치를 고지한다. 베니스에서 10년 동안 발명자의 동의없이 이러한 장치와 동일 또는 유사한 장치를 제조하는 것은 금지된다. 만일 침해가 발생하였다면, 발명자는 본 법률에 따라 베니스 관청에 제소하여 소위 침해자에게 100 두카티의 액수를 청구할 수 있고, 불법으로 이루어진 장치의 복제물을 즉시 파괴할 수 있는 권리를 가진다. 만일 발명자에 의해 직접 제조된 장치가 공익을 위하여 필요하다고 인정된다면 왕은 신규하고 창작적인 당해 발명인 장치를 이용하게 할 수 있다.

상기에서 살펴본 바와 같이 베니스 공화국의 특허법은 오늘날의 특허제도와 일부 유사한 점을 가지고 있다. 우선 신규하고 창작성있는 발명에 대하여 독점배타적 권리로서 특허를 부여하였다는 점이다. 특허를 받기 위한 신청은 평의회(Senate)에 하는데, 평의회는 행정기관들(magistrates)에 선행적으로 필요한 조사와 보고를 할 책임을 지우게 된다. 이때 자문 역할을 담

당할 행정기관에 대한 선택은 발명의 유형에 따라 달라진다.⁶⁾ 이들 행정기관들에 의해 특허출원에 적용될 선행 조사는 1474년 베니스 공화국의 특허법 하에서 몇 가지 요건, 예컨대 가동성(operability), 신규성 및 유용성 여부를 중심으로 행하여진다. 이때 신규성에 대한 선행심사는 이의신청이 있는 경우에만 필요한 조사가 행하여졌고, 가동성과 유용성에 대한 심사는 아직 신규 발명이 사용되지 않은 상태이기 때문에 담당 행정기관이 추상적이고 간결한 평가를 내렸던 것으로 보인다.⁷⁾ 베니스 공화국에서 발명에 대한 특허권은 ‘창작성 있는 장치’를 처음 사용하여 베니스 공화국의 발전을 가져온 자에 대한 보상 차원에서 부여된 것이었다.⁸⁾ 그러나 유용성에 대한 심사는 담당 공무원의 자의적 판단 요소가 개입되어 발명자는 자신이 한 발명에 대하여 실질적으로 객관성을 담보받지는 못하였던 것 같다. 이와 같이 행정기관에 의한 선행조사는 객관성을 담보할 만큼 충분하게 진행되지 못하였기 때문에 추가 조사가 요구되기도 하였다.⁹⁾

베니스 공화국 특허법의 특징은 평의회에 의해 ‘특권(privileges)’이라는 이름으로 특허가 부여되었다는 점이다. 베니스 공화국은 순수한 특권 형태로 사안별로 특허를 부여하였는데, 최초의 특허는 인쇄업 관련 특허였던 것으로 알려지고 있다.¹⁰⁾ 한편 권리자에게 독점적인 권리를 부여한 것 이외에

6) Mandich, 전제논문, pp. 184-186. 예컨대, 수력 장치에 대한 발명을 한 경우에는 수력 위원회(Savi sopra le acque)로 보내진다.

7) Ibid., pp. 186-188.

8) Ibid., p. 195.

9) Ibid., pp. 189-190.

10) 대표적인 경우가 1469년 John of Speyer에게 부여된 특허로, 그는 베니스공화국에 새로운 종류의 인쇄기를 선보여 보호를 받았고, 이를 시작으로 1500년 경에는 수많은 관련 특허가 부여되었다고 한다. 베니스에서 1517년까지 인쇄업자에 대한 특허업무는 내각(Cabinet)이 담당하였지만, 통상적인 발명에 대한 특허업무는 평의회(Senate)가 담당하였다. 그러나 1517년 이후 내각의 특허 업무는 평의회에 인수되었다. 상세한 내용은 Mandich, 전제논문, p. 169, p. 201 이하 참조.

도 출원인이 특허 벤처를 위하여 많은 비용이 필요한 점을 배려하여 ‘면세’ 특혜가 주어지기도 하였다. 이는 다각도로 발명자를 배려함으로서 자국의 산업발전을 도모하려고 한 베니스 공화국의 정책적 의지를 엿볼 수 있는 부분이다. 그러나 일부 독점권은 지역이 한정되어 부여되기도 하였는데¹¹⁾ 이는 베니스 공화국이 사권인 특허 부여에 객관성 또는 공정성을 담보하지 못하고 오히려 자의적 판단에 의하였음을 알 수 있는 부분이다.

한편 1474년 베니스 공화국의 특허법은 발명의 보호기간과 관련하여 10년 동안 독점적 권한을 부여하였는데, 보호기간은 행정기관의 임의적 판단에 의해 시대에 따라 달라졌다고 한다.¹²⁾ 재미있는 것은 일반적으로 보호기간이 지나치게 오랫동안 부여되었거나 해당 발명이 사회 공동체를 위하여 특별히 유용하다고 판단되는 경우에는 행정기관의 자의적 판단에 의해 특허의 보호기간을 단축시키기도 하였다는 점이다.¹³⁾ 발명자들 중 일부는 특허권을 부여받지 않고 대신 신규 발명의 이용을 공중 또는 국가에 양도함으로써 재정적 보상을 요구하기도 하였고, 일부 발명자는 보너스 또는 독점권 중 어느 하나를 택할 수 있는 권한을 보유하기도 하였다.¹⁴⁾

베니스 공화국의 특허법에 의하면 발명에 대한 침해가 발생한 경우에 베니스 관청에 제소하여 침해자에게 벌금을 청구¹⁵⁾할 수 있었고, 또한 불법으

11) Ibid., pp. 190-192.

12) 특허보호기간에 대하여 출원인은 1400년대 후반기에는 50년을, 1500년대 전반기에는 25년 또는 50년을 요구하였다. 행정기관(magistrate)은 신청받은 기간을 수용하기도 하였지만, 드물게는 10년으로 단축하는 경우도 있었다. 통상 1474년부터 1500년까지는 50년, 1500년부터 1550년까지는 25년의 기간이 부여되었는데, 두 경우 모두 5년으로 단축되는 경우도 있어 행정기관의 임의적 판단에 따라 보호기간이 달라졌다고 할 수 있다. Mandich, 전제논문, p. 192.

13) Ibid., p. 192.

14) Ibid., p. 193.

15) Ibid., p. 192. 벌금은 통상 수 백 두카트(a few hundred ducats)를 지불하였는데,

로 이루어진 침해 물품인 장치를 즉시 폐기할 것을 청구할 수도 있었다. 또한 베니스 공화국의 특허법은 발명자를 보호하기도 하였지만 공익을 위하여 제3자인 왕이 실시할 수 있도록 하는 강제실시권을 인정하고 있었다.¹⁶⁾

나. 베니스 공화국 특허법의 의의

베니스 공화국의 특허법은 세계에서 가장 오래된 특허법으로 알려져 있지만, 오늘날의 특허법과 비교할 때 너무 과대평가해서는 안 될 것이다. 왜냐하면 베니스 공화국의 특허법이 시행되기 이전에 활용되었던 관습법이 베니스 공화국의 특허법이 시행된 이후에도 계속 중요하게 작용하였던 것으로 알려져 있기 때문이다. 예컨대 베니스 공화국의 특허법이 제정된 지 100년이 지난 1594년 갈릴레오 갈릴레이는 특허법에 의해서가 아니라 관습법에 의해 자신의 양수장치 관련 발명의 보호를 호소하였다.¹⁷⁾ 또한 베니스 공화국의 특허법에서 주목할 점은 발명을 특권으로서 보호한 것이 국가에 의한 부여행위에 의해서가 아니라 사적인 계약행위에 의존하였다는 점이다.¹⁸⁾ 베니스 공화국의 특허법에서 유용하였던 것은 발명에 대한 법적 보호를 위한 유일한 방법으로서 바로 ‘특권을 부여’하였다는 점인데, 이러한 경우에도 행정관청의 임의적 판단에 의해 특허의 보호기간이 연장 또는 단축되기도 하고, 정책적 판단에 의해 ‘면세’라는 특혜가 주어지기도 하였으며, 국가에 의해 때때로 권리의 효력이 일부 지역으로 제한되는 등

드물게는 금고형에 처하는 경우도 하였다.

- 16) ‘공익’에 해당하는 경우가 어떠한 경우인지에 관하여는 아직 알려진 바 없다.
- 17) 갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei, 1564년 2월 15일~1642년 1월 8일)는 이탈리아 출신의 철학자, 과학자, 물리학자, 천문학자이다. 그는 망원경을 개량하여 관찰, 운동 법칙을 확립하였고, 코페르니쿠스의 이론을 옹호하여 태양계의 중심이 지구가 아니라 태양이라고 믿었다. 갈릴레이는 단지 말 한 마리를 이용하여 20개의 도랑으로부터 끊이지 않고 물을 끌어올려 토지에 급수할 수 있는 특징을 가진 양수장치를 발명하였는데, 이 장치는 나중에 특허가 부여되었다.
- 18) Rudolf Krasser, Patentrecht, 5. Aufl., C. H. Beck, 2004, p. 55. 이에 관하여 발명자가 어떠한 혜택을 입었는지에 관하여는 아직 보고된 바 없다.

주관적 요소가 상당히 개입되어 객관성을 담보하지 못한 불합리한 면들을 내포하고 있었다. 이는 베니스 공화국이 자국의 산업 발전을 위하여 특허라는 제도를 정책적으로 이용하였기 때문인 것으로 판단된다. 그러나 베니스 공화국은 필요에 따라 특허를 부여한 것이 아니라 지속적으로 일정한 규칙에 따라 특허를 부여한 최초의 국가라고 하는 점에서 유의미하다. 예컨대, 특허보호기간이 유한하였고, 발명이 유용한 경우에 발명자에게 일정한 보호를 인정하였으며, 부여된 권리는 이전 가능하였고(*inter vivos and mortis causa*), 공익을 위하여 강제실시권이 인정되었으며, 베니스 공화국 내에서 선행기술이 있는 경우에는 특허가 실시되지 못하도록 하였고, 침해 발생 시 일정한 범위 내에서 침해에 대한 구제조치를 마련해 놓는 등 오늘날 특허제도와 유사한 제도를 가지고 있다. 한편 베니스 공화국의 특허 제도는 영국을 포함하여 유럽대륙으로 전파된 것으로 추정된다.¹⁹⁾

2. 16세기 이후 특허보호(1600년－1850년)

가. 당시 유럽의 상황

16세기 중반까지 유럽의 일부 지역에서는 ‘특권(Privileges) 부여’ 원칙이 적용되었는데, 이러한 특권부여 원칙은 오늘날의 특허제도와는 크게 달랐다. 당시 대부분의 특권들은 발명자에게 보상하고 기술 혁신자(*innovator*)를 보호하는 것이었는데, 제한적인 규제로부터 기술혁신자를 풀어주려고 했던 것은 산업발전을 촉진시킬 목적이 아니라 단지 왕실의 충애를 입은 자 또는 국왕의 재정을 지원하는 자에게 수익이 있는 독점권을 부여하는 것에 불과하였다. 즉 왕실의 재원을 충족시킬 목적으로 또는 외국으로부터 수입으로 인하여 국가 재정이 해외로 빠져나가는 것을 방지할 목적으로 특권 제도가 활용되었다. 특권이라는 혜택을 입은 자들은 보호기간에 대한 연장까지 관대하게 승인받으면서 이익을 창출할 수 있는 독점권을 보장받게

19) Mandich, 전제논문, pp. 205-207.

되었다.²⁰⁾ 1560년 이후 영국에서는 이러한 종류의 독점적인 특허의 숫자가 셀 수 없이 많았다. 예컨대 소금, 식초, 청어, 소금에 절인 고기, 가죽제품, 비누 등에 대하여 독점권이 주어졌고,²¹⁾ 이와 같은 독점 현상에 대하여 대중의 불만은 증대되었다.²²⁾ 특히 17세기 영국의 엘리자베스 1세 여왕 시절에는 곤궁한 국가재정을 위하여 특허를 남발하였다. 대표적인 사례가 놀이용 카드에 특허가 부여된 ‘Case of Monopolies’라는 사건이었다. 본 사건에서 법원은 1603년 놀이용 카드에 대하여 수입 및 판매 독점이 보통법(Common Law)에 근거하여 무효라고 판시하였다.²³⁾ 이와 같은 특권의 남용에 대하여 영국에서는 즉시, 프랑스에서는 프랑스대혁명 중에 모든 독점 및 특권을 폐지하라는 저항운동이 일어났다.²⁴⁾ 이러한 분위기 속에 특권 부여로 인한 왕실과 의회의 갈등이 깊어져갔다.²⁵⁾ 특권남용을 비난하여 왔던 영국 의회는 제이콥 1세(Jacob 1.) 시절인 1624년 ‘독점조례(Statute of Monopolies)’를 제정하게 된다.

한편 16세기에 독일에서는 군주들이 특허권을 널리 이용하였다. 일부 군

20) Silberstein, *Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien*, Zürich 1961, p. 194, p. 215, p. 238; Krasser, 전제서, p. 55.

21) Silberstein, 전제서, p. 194, p. 199; Krasser, 전제서, p. 56. 1582년에 윌리엄 브라운이 부여받은 ‘염의 제조방법’ 특허는 그의 해외무역의 손실에 의한 궁핍한 재정을 구제하기 위해 부여되었고, 다른 한편으로는 상인에게 부여된 특권과 제조업자에게 부여된 공업상의 보호가 혼재하였다.

22) Harold G. Fox, *Monopolies and Patents* (Toronto: University of Toronto Press, 1947), 85, pp. 125-126.

23) 엘리자베스 1세는 통치 말기인 1601년 Proclamation concerning Monopolies를 공포 하라고 하는 압력에 직면하였으며, 이후 놀이용 카드에 대하여 엘리자비드 1세가 부여한 특허 독점이 보통법에 의해 무효라는 소송이 제기되었다. 이 소송은 그녀가 사망한 이후에나 판결되었다. Machlup, 전제논문, p. 374; Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property*, Sweet & Maxwell, 2003, pp. 112-113.

24) Krasser, 전제서, p. 55. 그러나 양 국가에서 새로운 발명에 대하여 일시적인 보호를 인정해야 한다는 의식은 여전히 존재하였다.

25) Giulio Mandich, *Venetian Patents (1450-1550)*, J. of the Patent Office Society, p. 168.

주들은 유용성과 신규성을 만족시키는 발명자의 발명을 제3자가 무단으로 사용하지 못하도록 하였고, 특허권자가 값비싼 가격으로 자신의 특허발명 제품을 판매할 수 있도록 특권을 부여하는 정책을 채택하였다.²⁶⁾ 배타적인 특권이 부여된 발명들 중 일부는 신규 발명에 대하여 부여되었지만, 다른 일부는 해외에서 수입한 숙련된 기술들에 부여되는 경우도 있었다. 이와 같이 부여된 특권들은 제한된 기간 동안 부여되었지만, 때로는 영구적으로 부여된 경우도 있었다.²⁷⁾ 일부 특권들은 제3자의 모방에 대하여 법적 보호를 받아 독점적인 권리를 창출하기도 하였지만, 어떤 경우에는 제한적인 길드 규정으로부터 보호받아 기존의 독점적인 지위를 낮추고 오히려 경쟁을 증대시키는 특권의 경우도 있었다. 후자의 경우에 특허는 때때로 산업을 제한적인 길드 규정으로부터 해방시켜 산업혁명에 도움을 주려고 하였던 것에 기인한 것이었다. 그러나 프랑스에서는 18세기에도 기술혁신을 이룩한 사람들을 숙련공 길드 조합이 박해하는 현상도 있었다. 한편, 왕정으로 부여되는 특권 중에는 때때로 기존의 규칙 하에서 금지되었던 것을 허용하는 경우도 있었다.²⁸⁾

이하 각 국에서의 특허제도에 관하여 살펴보도록 한다.

나. 영국의 독점조례(Statute of Monopolies)

특허법의 역사에서 오늘날의 특허제도와 유사한 성격을 지닌 세계 최초

26) 예컨대, 색소니의 어거스트(August of Saxony)는 1588년에 새로운 발명들에 대하여 10년의 특권을 부여하는 정책을 펼쳤다, Fritz Hoffmann, “16세기 독일에서 발명 보호사에 관한 기고문(Beiträge zur Geschichte des Erfindungsschutzes in Deutschland im sechzehnten Jahrhundert)”, Zeitschrift für Industrierecht, vol. X (1915), p. 89.

27) 예컨대, 스위스의 베른주는 1577년에 발명자인 조벨(Zobell)에게 “영원한 배타적 특권(permanent exclusive privilege)”을 부여하였다고 한다, Fritz Machlup, An Economic Review of the Patent System, 1958, p. 2.

28) Augustin-Charles Renouard(오귀스탱-샤를 르누아르), Traité des brevets d'invention (발명특허의 범위) (Paris: 3d. edition, 1865), p. 43.

의 특허법은 1624년 영국에서 제정된 ‘독점조례(Statute of Monopolies)’이다. 독일의 Kohler 교수는 “발명자의 권리에 대한 마그나카르타(Magna Charta der Erfinderrechte)”²⁹⁾라고 일컬을 정도로 극찬하였는데, 이는 ‘독점조례’에서 ‘최초의 진실한 발명자(der erste und wahre Erfinder)’에게 독점특허를 부여한 점을 높게 평가하였기 때문이다. 독점조례를 근대 특허제도의 발원이라고 보는 다른 이유로서는 신규 발명에 대해서만 독점권을 부여하고 그 이외의 독점은 인간의 자유와 이익을 침해하는 것으로 인정되어서는 안된다는 사고가 작용하였던 것으로 풀이된다.³⁰⁾

16세기 이래 유럽에서는 기술혁신을 위하여 인센티브로서 독점적 특허를 시장에 부여하려는 사고방식이 통상적으로 존재하였다. 이러한 사고방식은 영국에서도 다른 유럽의 국가들과 마찬가지로 왕실의 은혜의 형태로 표출되었다. 엘리자베드 1세(Elizabeth I)로부터 행하여진 이러한 관행은 제임스 1세(James I)에도 계속되어 제임스 1세는 자신의 정치적 후원자들에게 특허장을 부여하여 무역상의 독점권을 부여하기도 하였다.³¹⁾ 그러나 특권남용에 대하여 비판적인 자세를 견지하여 왔던 영국의회는 1624년 신규제조물을 발명한 ‘최초의 진실한 발명자’에게 14년간 특허 독점적 권리를 부여하는 경우를 예외로 인정할 것 이외에는 국왕(Crown)이 배타적 권리를 부여하는 것을 금지하는 ‘독점조례’를 제정하였다.³²⁾ 그 배경을 살펴보면,

29) Kohler 교수는 영국의 ‘독점조례’를 한편으로는 ‘발명자 보호의 마그나카르타’로, 다른 한편으로는 ‘교역자유(Verkehrsfreiheit)의 마그나카르타’로 규정짓고 있다. 전자의 경우 ‘독점조례’는 금지되어야 할 ‘전횡(Willkür)’의 영역으로부터 발명에 대한 독점을 제외시킴으로써 발명자의 특별한 입장과 발명자의 정당한 요구를 인정하였고, 후자의 경우 ‘독점조례’는 다른 유형의 독점을 금지함으로써 행정적 판단과 평가의 개입으로부터 교역(Verkehr)을 자유롭게 만들었다고 주장한다, Josef Kohler, Ibid., p. 19.

30) 竹田和彦, 特許の知識, 다이iamond社, 2006, 2면 이하.

31) Cornish & Llewelyn, 전게서, pp. 112-3.

32) Section 6 참조.

당시 유럽에서는 기술 경쟁에서 상대적 우위를 차지하기 위하여 특허제도의 중요성이 부각되었는데, 영국은 프랑스와 네덜란드에 비해 기술적으로 상대적 열세에 놓여있었고, 또한 발명자는 발명의 고안자이기도 하지만 동시에 [자국에 유용한] 발명을 해외로부터 수입하는 사람이라고 이해되었던 측면이 부각되었다.³³⁾ 따라서 영국에서 독점조례가 입법화된 배경에는 발명자의 노력에 대하여 특허라는 인센티브를 부여한다기보다는 오히려 자국의 산업, 고용, 성장을 촉진하려고 하는 경제정책이 더욱 중요하게 고려되었던 것이다.

‘독점조례’ Section 6에 따르면 “국내 일용품의 가격을 상승시키거나 무역을 해치거나 일반적으로 불편하다고 해서 [특허에 의해] 보호받은 제조물이 법을 위반하거나 국가에 위해가 되는 것은 아니다(The protected manufactures were not to be contrary to the law nor mischievous to the State, by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient)”라고 한다. 이는 특허라는 독점권 부여의 정당성을 인정하고 있는 규정으로 볼 수 있다. 한편 신규 발명에 대하여 정당성이 부여되는 경우를 제외하고는 거의 모든 특권을 폐지하도록 하였는데, 이러한 예외 규정이 유의미한 것은 신규발명에 대한 법적 보호 또는 외국으로부터 최초의 수입물에 대한 보호가 보통법(Common Law) 원칙과 충돌하지 않으며, 영국이 설령 법제사적으로 특허권을 부여한 첫 번째 국가는 아닐지라도 ‘실체법(law)’에 의하여 발명자를 보호하는 세계 최초의 국가로 높게 평가받고 있기 때문이다.³⁴⁾

다. 미국의 특허법

독점조례는 현행 영국 특허법의 근거가 됨은 물론 다른 제 외국의 특허법의 모델이 되었다. 최초로 독점조례를 따라 특허법을 제정한 국가는 미

33) Cornish & Llewelyn, 전게서, p. 113.

34) G. Mandich, 전게논문, p. 168.

국이였다. 영국의 청교도 102명이 메이플라워호를 타고 매사추세츠 주에 도착한 것은 1620년 11월 19일로 영국에서 독점조례가 제정되기 3년 전이었다. 발명의 중요성을 인식한 이들은 식민지에서 누구라도 사용할 수 있도록 도구를 개량한 자에게 특별한 권리를 부여하려고 하였다. 1641년 매사추세츠 주의회는 어떠한 독점권도 허용될 수 없지만 국가에 유용한 새로운 발명을 한 발명자에 대하여 단기간 독점실시를 할 수 있도록 허용하는 특허제도를 제정하였고, 최초로 사무엘 윈스로(Samuel Winslow)의 식염 제조방법 발명에 대하여 10년간 특허권을 부여하였다.³⁵⁾ 미국에서 특허제도는 매사추세츠 주(1641년)로 한정되지 않고, 코네티컷 주(1672년), 사우스캐롤라이나 주(1691년) 등에서 만들어졌는데, 이들은 왕실에 의해 특허를 부여하는 경우와는 다른 “일반(general)” 특허법의 형태로 제정되었다. 이들 규정을 참조하여 1787년 9월 17일 미국헌법 Art I Section 8에서는 “의회는 …저작자 또는 발명자에게 이들의 저작물 또는 발견에 대하여 일정기간 배타적 권리를 보장함으로써 과학과 유용한 예술의 진보를 도모할…권한을 가진다(The Congress shall have Power…to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries)”라고 규정하였고,³⁶⁾ 이 규정에 의해 미국은 영국의 독점조례를 참조하여 1790년 8월 10일 저작자와 창작자, 예술가와 산업계의 작품에 관한 재산권을 인정하는 특허법을 제정하였다.³⁷⁾

35) Robert Choate / William Francis / Robert Collins, Cases and Materials on Patent Law, West Publishing Co., 1987, pp. 68-69.

36) 이 규정은 이미 특허법과 저작권법의 제정 실현에 성공한 버지니아 주 대표인 제임스 매디슨(James Madison)과 사우스캐롤라이나 주 대표인 찰스 핀크니(Charles Pinckney)의 1787년 8월 18일 연방헌법제정회의에서의 제안에 의해 이루어졌다. 그 후 연방헌법제정회의는 이 제안을 전원일치로 채택하였고, 이 내용은 지금까지도 수정되지 않은 채 그대로 존속하고 있다. 상세히는 Robert Choate / William Francis / Robert Collins, Ibid., p. 69; 石井 正, 전거서, 79면 이하.

37) 이 규정에 대하여 James Madison은 The Federalist No. 43에서 다음과 같이 주장하고 있다: “이 규정의 유용성은 의심의 여지가 없다. 저작자의 저작권은 보통

라. 프랑스의 특허법

프랑스에서는 절대주의 왕정 시절에 부여되었던 특권이 제조업 분야의 생산을 촉진하는데 중요한 역할을 하였다. 당시 새로 설립된 왕실의 수공업 제품들은 이전에 특권 혜택을 누린 자에 반대하였는데,³⁸⁾ 특권을 상실시키고 더욱 엄격한 실시의무를 부과하는 것이 당시 경제정책의 목표였다. 발명자에 대한 특권은 비교적 드물었고, 특히 1659년 이후 시행된 기계류 특권신청에 대한 왕정 아카데미의 심사는 실무상 별로 중요하지 않았다.³⁹⁾ 그러나 자유주의적 사상의 영향 하에 경제정책을 위한 수단으로서 특권제도는 거의 무용지물하게 되었고, 1762년에 루이 15세는 “창작정신의 발전 및 산업의 진보를 촉진시킬(stimuler le développement de l’esprit inventif et du progrès de l’industrie)” 목적으로 발명자에게 특권을 부여하기는 하지만, 영구적인 특권은 금지하고 특권의 기간과 상속을 제한한다는 칙령을 공포하였다.⁴⁰⁾ 그러나 1789년 프랑스대혁명이 성공을 거두면서 일체 특권제도의 폐지를 요구하는 사회의 목소리가 높아지면서 발명특권을 포함한 모든 특권제도가 폐지되었다. 그 후 특허보호 하에 활발하게 기술개발을 진행하고

법에서 권리가 인정되는 영국에서만 적용되어 왔다. 유용한 발명에 대한 권리는 동일한 이유로 발명자에게 귀속되는 것 같다. 공익은 두 경우 모두 개인의 주장과 완전 일치한다.” 한편 발명에 대한 발명자의 천부적 권리에 관하여 미 연방법원은 1913년 *Bauer & Cie. v. O'Donnell*, 229 US 1. 사건에서 “발명에 대한 권리는 특허법에서 유도된 것이 아니라, 이미 존재하였던 권리로 법률의 통과에 의해 부여된 것이 아니고, 항상 발명자의 권리였다...독점적인 특권 기간이 만료된 이후에나 제3자는 이와 같은 발명을 사용하여 이익을 얻을 수 있다.”라고 판시하고 있다, Robert Choate / William Francis / Robert Collins, *Ibid.*, pp. 69-70.

38) Silberstein, *ibid.*, pp. 215, 221, 234.

39) 예컨대, 파스칼의 계산기(1649년), 호이겐스의 시계(1657년과 1675년) 등 매우 소수였다, Krasser, *ibid.*, p. 57.

40) Joanna Schmidt-Szalewski / Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle(산업재산권법)*, 3^e édition, Litec, 2003, p. 5; Neumeyer, *Die historischen Grundlagen der ersten modernen Patentgesetze in den USA und Frankreich(미국과 프랑스에서 최초 현대 특허법의 역사적 기원)*, GRUR Int. 1956, p. 247.

있었던 영국을 보면서 발명보호의 중요성을 인식하게 되었다. 그러나 절대 왕정 체제하 경제정책의 도구로서 모든 종류의 독점은 수용될 수 없었던 사회 분위기 때문에 발명에 대한 보호는 어떤 새로운 법적 정당성을 필요로 하게 되었다. 이러한 법적 정당성은 발명자가 자신의 발명에 대한 ‘천부적 재산권’을 가진다는 사고로부터 기인하게 되는데, 특히 발명특허는 발명자의 자연적 권리로 이는 사회적 계약에 근거한다는 루소⁴¹⁾의 사상으로부터 많은 영향을 받게 되었다.⁴²⁾ 1791년 의회에 제출한 보고서에서 부플레(Boufflers)는 “인간을 위하여 실질적인 재산이 존재한다면 이는 바로 생각(*pensée*)에 관한 것이며, 이는 발명자와 사회 사이의 계약을 분석하여 입증할 수 있다”라고 밝히고 있다. 이러한 사고는 1791년 1월 7일 제정된 프랑스 최초의 특허법에 크게 반영되었다.⁴³⁾ 프랑스 특허법에서는 발명자가 창작한 물(*res*)에 대한 발명자의 권리를 ‘인권(*droits de d’homme*)’에 입각한 ‘재산권(*droits de propriété*)’으로, 정신적인 재산권으로서 자연법에 근거를 두고 있는 것으로 규정하고 있다. 이는 발명자의 권리를 재산적인 권리라기보다는 인간의 본질적인 천부적 권리로 인정한다는 의미로 해석될 수 있다. 한편 1791년 프랑스 특허법 전문(前文)에는 새롭고 유용한 아이디어의 고안이 고안자의 재산권이 아니라 인격권적 요소로 보아야 하고, 산업상 발견과 저작자의 재산과는 서로 다르다는 내용이 기재되어 있다:

“모든 신규한 아이디어의 표현 또는 발전이 사회에 유용한 경우에 이러한 아이디어는 무엇보다도 이를 고안한 자에게 귀속되어야 하고, 이를 침해할 경우 본질적으로 인권을 침해하는 행위이다. 또한 산업상 발견을

41) 장 자크 루소(Jean-Jacques Rousseau, 1712년 6월 28일-1778년 7월 2일)는 스위스 제네바 태생의 낭만주의 철학자로, 사회 내부의 모든 구성원들은 그들의 선택에 의해 그리고 폭력적 계약 없이 사회 안에 존재하게 된 사회계약의 조건들에 동의하는 것을 받아들인다는 “사회계약론(1762)”을 발표하였다.

42) J. Schmidt-Szalewski / J. L. Pierre, Ibid., p. 5.

43) Ibid., p. 5.

산업재산권 제25호

저작자의 재산권과 동일하게 간주해서는 안된다(…toute idée nouvelle, don't la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur).”

프랑스 특허법에서는 발명에 대한 배타적 이용권이 보장되었고, 특허 담당 관청으로 발명특허부(Directoire des Brevets d'invention)가 설립되었으며 여기에서 발명의 분류작업이 진행되었다. 한편 프랑스 특허법은 영국과 비교할 때, 신규성 또는 유용성에 대한 심사를 하지 않았다고 하는 특징을 가지고 있다.⁴⁴⁾ 프랑스는 특허 이외에도 서적 생산 및 판매가 벨기에를 포함하여 유럽 제 국가들에 의해 해적행위가 이루어지는 것을 파악하고 1840년 이후부터 ‘해적행위(Contrefaçon)’에 대한 조약 체결에 힘을 쏟았다.⁴⁵⁾ 그 후 프랑스 특허법은 여러 차례 개정을 해 왔는데, 예컨대 특허 관련 행정 체제를 정비하였던 1844년 7월 5일자 개정, 유럽특허조약(European Patent Convention)을 시행하기 위한 1978년 7월 13일자 개정 등을 들 수 있으며, 현행 특허법은 생명공학발명의 특허법상의 보호를 규정하기 위한 2004년 12월 8일 개정된 법이다.

마. 오스트리아의 특허법

이후 특허법을 제정한 국가는 오스트리아이다. 오스트리아는 중상주의 경제정책의 수단으로서 특권이 부여되었다. 18세기 초반 이러한 특권들은 새로운 공장제 수공업 설립을 위하여 그리고 기존의 수공업을 유지하기 위하여 유용하였지만, 이에 대한 비난여론이 들끓자 특권 부여와 이를 연장하려는 움직임이 제한을 받았다.⁴⁶⁾ 18세기 후반 오스트리아는 영국의 새로운 기술들

44) Krasser, Ibid., 57면.

45) Barbara Dölemeyer, Wege der Rechtsvereinheitlichung in: Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag, Vittorio Klostermann Frankfurt am Main 1982, pp. 66-67.

46) Krasser, Ibid., pp. 58-59.

과 접촉하면서 발명보호에 관심을 가지게 되었고, 마침내 1794년 칙령을 통하여 발명특권에 관한 원칙들을 제정하였다. 이때 신규성을 중요하게 취급하여 특권이 부여된 경우에 자국 내 실시의무를 부과하였다. 한편 당시 특권에 대한 신청은 주로 기계, 특히 직물기계에 대해 증가하였다.⁴⁷⁾ 이러한 분위기 속에 1810년 오스트리아에서 최초로 특허법이 제정되었다. 동법에 의하면 특권은 국왕의 은혜이며, 새로운 발명은 보호기간이 경과하면 완전 공개되어야 했다.⁴⁸⁾ 동법은 발명자에게 천부적인 권리와 발명에 대한 재산권을 인정하지 않았다. 단지 공익에 부합할 경우에는 오스트리아 정부가 발명자의 천부적 자연권을 제한하여 발명자의 아이디어를 모방하는 특권을 부여할 수 있다고 규정하였다.⁴⁹⁾ 그 후 오스트리아 특허법은 프랑스법의 영향을 받아 1820년에 개정되었는데, 담당 관청에 의해 보호요건 심사가 진행되거나 특허부여에 특별한 청구가 요구되지도 않았다.⁵⁰⁾ 그러나 오스트리아 특허법은 실시의무를 중요시하게 취급하여 1년 동안 발명을 불실시할 경우에 발명을 소멸시켜 제3자가 이용할 수 있는 길을 열어놓았다. 1820년 개정법은 그 후 1832년과 1852년에 일부 개정되었다가 1897년에 전면 개정되었다.⁵¹⁾

바. 소결

상술한 바와 같이, 중세 이후 대표되는 국가의 특허법을 보면 발명자 권리의 성질에 대하여 4가지로 분류할 수 있음을 알 수 있다.⁵²⁾

첫째, 프랑스의 법률은 발명에 대한 발명자의 재산권을 인정하고, 이로

47) Ibid., p. 59.

48) Ibid., p. 59.

49) F. Machlup, Ibid., p. 374.

50) Schönherr F., Zur Geschichte des österreichischen Patentrechts, in: AIPPI (Hrsg.), La legge veneziana sulle invenzioni, Scritti di diritto industriale per il suo 500^o anniversario, Mailand 1974, pp. 223-236; Krasser, Ibid., p. 59 재인용.

51) Krasser, Ibid., p. 59.

52) F. Machlup, Ibid., p. 374.

부터 특허를 얻을 수 있는 발명자의 권리가 파생된다고 하였다.

둘째, 미국의 법률은 재산권 문제에 대하여는 침묵하고 있지만, 특허를 받을 수 있는 발명자의 법적 권리를 강조하고 있다.

셋째, 영국의 법률은 특허의 독점적인 성질을 인정하고, 이론적으로는 이를 국왕의 특혜에 의한 부여라고 보고 있지만, 실제로는 발명자가 규정에 따라 자신의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 신청을 허용하고 있다.

넷째, 오스트리아의 법률은 발명자가 보호를 받을 수 있는 어떠한 권리도 가지고 있지 않지만, 경제 정책적 이유에 의해 공익에 부합할 경우 특권 부여를 인정하고 있다.

발명자의 권리에 대한 이러한 차이점들에도 불구하고, 실정법에 의해 발명자를 보호하는 제도라고 하는 측면에서 특허제도는 다른 국가들에게 전파되기 시작하였다. 예컨대 러시아 1812년, 프로이센 1815년, 벨기에와 네덜란드 1817년, 스페인 1820년, 바이에른 1825년, 사르디니아 1826년, 바티칸공화국 1833년, 스웨덴 1834년, 뷔르템베르크 1836년, 포르투갈 1837년, 작센 1843년에 특허법을 제정하였다.⁵³⁾

3. 특허폐지 운동(1850년—1873년)

19세기 중반 이전까지는 특허제도를 강화 및 팽창시키려는 움직임이 있었다. 예컨대, 영국에서는 특허를 보다 용이하게 취득할 수 있도록, 그리고 더욱 효과적으로 시행될 수 있도록 하였다. 또한 독일에서도 1842년의 관세동맹협정이 가맹국으로부터 특허제품의 수입을 허용하여 특허의 가치가 감소된 이후 통일 특허법을 제정하려는 움직임이 있었다. 특허보호를 하지 않았던 스위스에서조차 독일의 이해관계 단체의 압력도 있어서 특허법을 제정하려고 하였다.⁵⁴⁾ 그러나 이러한 압력에 대한 반발로 유럽의 대부분의 국가에

53) Ibid., p. 374.

서는 당시의 자유무역운동과 함께 특허폐지 운동이 일어나기 시작하였다.⁵⁵⁾

영국에서는 ‘독점조례’ 시행 후 200년 동안 특허법 개정안이 의회에 제출되지 않았다. 그러나 1827년 특허 절차 비용이 너무 비싸고, 서투르고 불확실하다는 불평 등으로 인하여 특허제도를 완전 폐지하려는 움직임이 있었고, 대표주자는 런던 이코노미스트지(London Economist), 무역부(Board of Trade) 부의장 등이었다. 이에 대하여 의회위원회와 왕실위원회는 1851년-1852년, 1862년-1865년, 및 1869년-1872년에 걸쳐서 특허제도의 운용을 조사하였다. 그 결과, 특허제도의 평판을 매우 나쁘게 하는 몇 가지 증거가 나타났다고, 정치가들은 특허제도의 폐지를 주장하였다.⁵⁶⁾ 특히 특허출원에 대한 심사를 보다 엄격하게 하고, 보호기간을 7년으로 단축하며, 모든 특허에 있어서 강제허락을 규정하는 개정된 특허법(안)이 귀족원(House of Lords)을 통과하였다.

독일에서도 발명특허에 대하여 강력하게 반발하는 움직임이 포착되었다. 이는 특허옹호론자들이 각 주에서 특허보호를 강화하기 위한 입법을 요구하는 것에 대한 반발심리가 작용한 데서 비롯되었다. 특히 경제학자들은 거의 예외없이 특허제도를 비난하면서 일부 상업단체 및 상업회의소가 특허법의 폐지를 권고하였다.⁵⁷⁾ 특허존폐에 관한 논쟁은 책, 팜플렛, 저널, 신문 등을 통

54) Ibid., p. 375.

55) Fritz Machlup and Edith Penrose, “The Patent Controversy in the 19th Century.” The Journal of Economic History, vol. X (1950), pp. 1-29.

56) 당시의 기록에 관하여는 Parliamentary Debates, The Economist, The Spectator, 및 The Westminster Review, John Lewis Ricardo Granville, Stanley, Sir Roundell Palmer, Robert A. Macfie 등의 증언, 위원회보고 및 의회연설의 선집의 경우에 다음의 것들이 있다: Robert Andrew Macfie, The Patent Question under Free Trade (London, second edition, W. J. Johnson, 1864) 및 R. A. M. (Macfie), editor, Recent Discussion on the Abolition of Patents for Inventions in the United Kingdom, France, Germany and the Netherlands (London: Longmans, Green, 1869).

57) “특허문제에 관한 프로이센 무역이사회의 감정서(Die Gutachten der preußischen

하여 변호사, 엔지니어, 경제학자, 입법자들에 의해 진행되었다. 1863년 존 프린스 스미스(John Prince Smith)는 독일 국민경제회의(Kongress deutscher Volkswirte)에서 특허부여가 법적으로 독점을 허용하며 산업활동을 저해한다고 주장하였고, 이에 따라 독일 국민경제회의는 “발명특허가 공공의 복지를 해치며 따라서 특허제도의 폐지를 권면한다.”라고 하였다.⁵⁸⁾ 당시 경제자유주의 및 자유무역논리는 프로이센에 커다란 영향을 미쳐 프로이센 정부는 1850년대와 1860년대 모든 특허 신청 중 거의 90%를 거절하였고, 특허제도의 폐지를 위하여 노력하였다.⁵⁹⁾ 수년간의 대중 토론을 통하여 프로이센 정부는 북독연맹이 특허법을 채택한 것에 반대하는 성명을 발표하였고, 당시 북독연맹의 수상이었던 비스마르크는 1868년 북독연맹 영역 내에 특허보호에 대하여 반대하는 입장을 발표하였다.⁶⁰⁾

유럽에서 특허법을 제정하지 않았던 유일한 공업국이었던 스위스에서는 특허제도의 채택을 주장해 온 스위스 쥐리히 공과대학(Zürich Institut of Technology) 회원들의 논거에 대하여 정부가 계속 반박하였다. 스위스 의회는 1849년, 1851년, 1854년 및 1863년에 특허법을 제정하려는 제안을 계속 부결시켰다. 당시 입법자는 최후의 부결에 있어서는 ‘가장 경쟁력있는 국민경제’를 위해서는 특허보호라고 하는 원칙이 “구제불능으로 비난받아 마땅하다.”라고 하는 극한 표현까지 사용하며 특허제도의 폐지를 주장하였다.⁶¹⁾

Handelsvorstände über die Patentfrage”, Vierteljahrschrift für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte, 2 Jahr (1964), No. 1, pp. 193-215.

58) 9월 14일, 15일, 16일 및 17일 드레스덴에서 열린 제6차 독일국민경제회의의 교섭 보고서(Bericht für die Verhandlungen des sechsten Kongresses deutscher Volkswirte zu Dresden am 14., 15., 16. und 17. September), Vierteljahrschrift für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte, 1. Jahr (1863), No. III, p. 221.

59) Krasser, Ibid., p. 62.

60) Hirth's Annalen des Norddeutschen Bundes (Berlin) 1868, pp. 39-42; Ibid., 1869, p. 33.

61) Offizielles Bundesblatt, Jahrgang 1864, No. II, pp. 510-511.

네덜란드에서는 자유무역주의 운동과 결부되어 다른 국가들보다 더욱 격렬하게 특허반대 운동이 일어났다. 특히 의회의 과반수가 “좋은 특허법을 제정하는 것은 불가능하다”라고 믿었고,⁶²⁾ 이러한 분위기 속에서 빅토르 뵘머트(Viktor Böhmert)가 “특허는 폐지되어야 할 상태에 이르렀고, 인류 문화라고 하는 나무에 잘못 열린 과실이라는 인식이 확산되고 있다.”라고 주장하기도 하였다.⁶³⁾ 결국 네덜란드에서는 특허폐지론자가 승리하여 1869년 7월 특허법이 폐지되었다.

4. 특허옹호론자의 승리(1873년 - 1910년)

1860년대 말에 특허보호에 대한 주장은 거의 설득력을 잃어버렸고, 특허폐지론자들의 주장이 지속될 것만 같은 분위기였다. 그러나 특허폐지론자들의 승리는 오래 지속되지 않았다. 특허옹호론자들은 강력하게 역공을 가할 조직을 구축하였고, 특허보호를 위한 새로운 움직임들이 1867년과 1877년 사이에 만들어졌으며, 특허보호 결의문들이 신문을 통해 세간에 알려지기 시작하였고, 대변인들이 무역협회 모임에 파견되었으며, 엄청난 양의 팜플렛과 광고전단지들이 뿌려졌고, 무역관련 학술지에는 특허보호 논문들이 실리고 다시 이들이 신문을 통해 알려졌으며, 일반인의 공개경쟁을 통하여 특허제도를 옹호하는 가장 우수한 논문들에 대하여는 시상이 주어졌고, 정부와 입법부에 청원서가 제출되었으며, 국제회의가 개최되는 등 특허보호 주창자들은 매우 활발하게 움직이기 시작하였다.⁶⁴⁾ 이러한 가운데 1873년

62) M. Godefroi, in the debate in the Dutch Parliament Quoted in the British House of Commons Sessional Papers, LXI, doc. 41 (Feb. 16, 1870).

63) Heggen, A., Die Anfänge des Erfindungsschutzes in Preußen 1793 bis 1815, GRUR 1974, 75-77면; Silberstein M., Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien, Zürich 1961, p. 276.

64) Edith Tilton Penrose, The Economics of the International Patent System, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1951, pp. 12-17.

에는 안티특허운동이 급격하게 붕괴하기 시작하였다. 이러한 급격한 변화가 일어날 수 있는 사회적 배경으로서 경제적 침체, 보호무역주의의 태동, 안티특허운동의 주된 사상적 지주로서 특허보호와 관세보호를 공격하였던 자유무역주의의 약화, 민족주의의 태동, 특허폐지론자들이 특허옹호론자와의 타협을 수용하려는 자세 등을 열거할 수 있다. 예컨대, 자유무역주의의 특허제도에 대한 부정적 자세는 상대적으로 기술자, 엔지니어, 기업가들로 하여금 개량된 발명특허보호에 대한 노력을 부추겼다. 이러한 가운데 특허옹호론자와 자유무역주의자는 특허권자의 독점권에 대한 제한에 대하여 논쟁을 벌인 결과, 상호 전략적 타협점을 찾았는데 바로 강제실시허락의 수용이 그것이다. 이러한 아이디어는 1790년에 미합중국의 상원에서,⁶⁵⁾ 1851년에는 영국의 귀족원에서,⁶⁶⁾ 1853년에 독일의 한 관료에 의해,⁶⁷⁾ 1853년, 1861년과 1863년에 영국의 과학단체의 여러 회의에서,⁶⁸⁾ 그리고 1873년에 오스트리아 비엔나 만국박람회에서도 개최된 특허회의에서⁶⁹⁾ 제안되었다.

또한 독일을 예로 들어보면, 독일에서는 1856년 독일기술자협회(Verein Deutscher

65) Record of the Proceedings in Congress Relating to the First Patent and Copyright Laws, printed by the Patent Office Society, edited by P.J. Federico (1940). 발명을 은닉하는 경우에 강제실시허락 제도가 1784년의 남부 캐롤라이나 특허법에 제정되었다. Pooling of Patents, Hearings before the House Committee on Patents on H.R. 4523, 74th Cong., pt. 4 (1935), pp. 3570-3571.

66) House of Lords, Parliamentary Debates, 1851 (July 1, 1851).

67) Al. Pilenko, 발명자의 권리(Das Recht des Erfinders) (Berlin: Heymann, 1907), p. 523.

68) Transaction of the National Association for the Promotion of Social Science, 1858 (London: 1859), p. 148; Report of Joint Committee with British Association for the Advancement of Science, Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science, 1861 (London: 1862), p. 230; Transactions of the York Meeting of the National Association for the Promotion of Social Science, 1863 (London: 1864), p. 664.

69) “발명자보호 및 특허법 개정(Der Erfinderschutz und die Reform der Patentgesetze)”: Amtlicher Bericht ueber den Internationalen Patent-Congress zur Erörterung der Frage des Patentschutzes (Dresden: 1873).

Ingenieure)가 설립되었다. 1869년에 루돌프 클로스터만즈(Rudolf Klostermanns)는 ‘모든 국가들의 특허입법(Patentgesetzgebung aller Länder)’에 있어서 특허 보호의 찬성을 주장하는 논리를 펼쳤다.⁷⁰⁾ 이외에도 경제적 침체는 ‘유해한 자유경쟁 및 자유무역 이론’을 인정하는 분위기를 조성하여 국민들로 하여금 자유무역주의에 등을 돌리게 만들었다. 독일제국 의회의원인 악커만(Ackermann)은 1877년 독일 특허법에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰다.⁷¹⁾ 독일에서 특허옹호론자들은 발명자가 신규 발명을 비밀로 유지하려는 움직임이 있으며, 특허보호가 발명활동을 자극하여 기술혁신을 위한 기업의 투자가 활성화될 것이라고 주장하였다. 또한 충분한 특허보호가 이루어지지 않을 경우 저개발상태에 이르게 되어 독일 산업제조물의 수출 역량이 감소하게 될 것이고, 많은 발명자들이 외국으로 이주할 것이라고 강조하였다.⁷²⁾ 이러한 분위기 하에 1871년 독일제국헌법은 발명특허에 대한 입법권(Gesetzgebungskompetenz)을 인정하였고, 1873년 경제위기로 인하여 자유무역 주장이 설득력을 상실하게 되면서 특허보호 비판론자들도 국가경제를 촉진시키는 수단으로서 특허보호제도를 수용하는 태도를 취하게 되었다.⁷³⁾ 특히 1873년 오스트리아 빈에서 열린 국제박람회와 국제특허회의에서 “법의식이 정신적 노동에 대한 법적 보호를 요구하고 있기 때문에 발명에 대한 보호는 모든 문명국가들의 입법에서 보장되어야 한다.”라는 주장도 있었다.⁷⁴⁾ 빈의 국제특허회의의 권면에 따라 독일에서는 독점에 대한 이의제

70) Krasser, 전제서, p. 62.

71) “강제실시허락 제도가 특허제도를 구하였다”라고도 주장되기도 하였다. Paul Beck von Mannagetta, “새로운 오스트리아 특허법(Das neue österreichische Patentrecht)” (Vienna: Hoelder, 1897), 17면; Franz Wirth, 특허개혁(Die Patent-Reform), (Frankfurt a. M.: 1875), 69면; Hermann Grothe, 독일제국의 특허법(Das Patentgesetz für das Deutsche Reich) (Berlin: Guttentag, 1877), p. 37.

72) Heggen, 전제논문, p. 324; Kohler, 전제서, p. 28.

73) Treue, W., Die Entwicklung des Patentwesens im 19. Jahrhundert in Preußen und im Deutschen Reich in: Coing, H. / Wilhelm, W. (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, Bd. IV, 1979, p. 173.

기를 피하기 위하여 권리자에게 적절한 보상이 이루어지면 특허권자가 제 3자의 이용을 허락하도록 하는 내용이 법령에 포함되도록 하였다.⁷⁵⁾ 독일은 1877년 5월 25일 특허법이 공포되었으며 동년 7월 1일 발효되었고, 제국 특허청(Kaiserliches Patentamt)이 베를린에 설립되었다.

반대론의 패배 또는 소멸은 일부 국가의 의회에 반영되었다. 영국에서는 귀족원을 통과한 급격한 개혁 법률안이 1874년 중의원(House of Commons)에서 부결되었다. 독일에서는 1877년에 통일특허법이 제정되었다. 1872년에 최초의 특허법을 제정한 후 1873년에 이를 폐지하였던 일본은 1885년에 별도의 특허법을 제정하였다. 다른 국가들보다 보수적인 스위스는 이러한 태도를 오랫동안 견지하였고, 1882년 국민투표에서 특허법을 거부하였지만, 1887년 다시 거행된 국민투표에서 의회가 특허법을 제정하였다. ‘발명의 자유무역’의 최후의 보루였던 네덜란드에서는 1910년 다시 특허제도를 도입하였고 1912년 시행하였다.

III. 맺음말

1. 오늘날 가장 오래된 특허법은 1474년의 베니스 공화국의 특허법이지만, ‘최초의 진실한 발명’을 보호한다는 의미에서 특허법은 ‘특허법의 마그나카르타’라고 불리우는 1624년 영국의 ‘독점조례(Statute of Monopolies)’이다. 중세의 절대왕정체제에서 특허보호는 통상 부실한 왕실재정을 충족시킬 목적으로 특권 형식으로 부여되었지만, 시민의 사회적 의식의 성숙 등과 함께 점차 성문법에 의한 특허보호로 권리가 부여되었다. 그러나 1850년 내지 1873년경 자유무역주의 등을 주창하는 경제학자들을 중심으로 특허제도 반대운동(Anti-Patent)이 전개되었고, 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드,

74) Krasser, 전게서, p. 63.

75) Heggen 전계논문, p. 326; Machlup, 전게서, p. 238; Krasser, 전게서, p. 63.

스위스를 중심으로 이러한 운동은 절정을 이루었다. 당시 반대론자들은 특허제도의 개혁이 아닌 폐지까지 요구하였다. 짧은 기간 동안 특허제도 폐지운동은 나름대로 성과를 거두었지만 경제 침체, 자유무역주의의 퇴조 등으로 인하여 다시 특허옹호론자들의 주장이 설득력을 얻게 되었다. 발명 특허에 대한 법적 보호는 19세기 후반을 거쳐 20세기에도 계속 지속되고 있다. 특히 19세기 후반에는 ‘산업재산권 보호를 위한 파리협약’ 등 특허 보호를 위한 국제조약이 체결되면서 특허제도의 국제화가 진행되었다. 최근 발명의 개념 확대, 특허보호에 대한 미국, 일본 등 선진국들의 특허중시(Pro-Patent) 정책, 특허침해에 대한 구제 강화 등을 통해 특허보호가 더욱 강화되는 방향으로 전개되고 있음을 알 수 있다. 21세기에도 역시 특허중시 정책은 각 국가의 중요한 산업정책으로 자리매김 될 것으로 전망된다.

2. 지적재산권 분야의 경우 우리나라는 주로 일본의 제도와 매우 유사한 측면을 가지고 있는데, 이는 법제사 측면에서 볼 때 특허법을 포함하여 지적재산권 제도들이 주로 일본을 통해 도입되었기 때문이라고 말할 수 있을 것이다. 그러나 이 분야의 발전을 위해서 앞으로 일본은 물론 미국이나 유럽의 지적재산제도에 관한 비교법적 연구가 반드시 필요하다고 생각한다. 이때 제외국의 입법의 개별 규정을 단순 비교하는 것이 아니라, 그 법규나 제도가 등장하게 된 배경, 입법과정, 당시 시대적 환경 등 법사학적 측면까지도 고찰하는 자세가 중요하다고 생각한다. 그렇기 때문에 우리나라와 같이 서양법학의 후발국들의 경우에 비교법학과 법사학을 연계시킨 연구의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없다고 생각하며, 이는 지적재산권 분야 역시 마찬가지일 것이다. 과거는 미래를 예측할 수 있는 중요한 척도라고 한다. 지적재산권 분야에서도 중세 이후 근대의 서구 지적재산제도에 관하여 법사학적 측면에서 바라본 비교법적 연구가 앞으로 활발하게 진행되기를 소망하며 이를 맺음말로 갈음하고자 한다.

[참고문헌]

- Busse, Patentgesetz, De Gruyter Recht · Berlin, 6. Aufl., 2003.
- Choate, Robert / Francis, William / Collins, Robert, Cases and Materials on Patent Law, West Publishing Co., 1987.
- Cornish, William / Llewelyn, David, Intellectual Property, Sweet & Maxwell, 2003.
- Doelemeyer, Barbara, Wege der Rechtsvereinheitlichung in: Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag, Vittorio Klostermann Frankfurt am Main 1982.
- Fox, Harold G., Monopolies and Patents, University of Toronto Press, 1947.
- Heggen, A., Die Anfänge des Erfindungsschutzes in Preußen 1793 bis 1815, GRUR 1974.
- Hoffmann, Fritz, Beiträge zur Geschichte des Erfindungsschutzes in Deutschland im sechzehnten Jahrhundert, Zeitschrift für Industrierecht, vol. X (1915).
- Kohler, Josef, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim, 1900.
- Krasser, Rudolf, Patentrecht, 5. Aufl., C. H. Beck, 2004.
- Kurz, P., Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, 2000,
- Machlup, Fritz, An economic review of the patent system, Washington 1958.
- Machlup, Fritz and Penrose, Edith “The Patent Controversy in the 19th Century.” The Journal of Economic History, vol. X (1950).
- Mandich, Giulio, Venetian Patents (1450–1550), Journal of the Patent Office Society, 1948.
- J. M. Mousseron, Traité des brevets, Librairies Techniques 1984.
- Neumeyer, Die historischen Grundlagen der ersten modernen Patentgesetze in den USA und Frankreich, GRUR Int. 1956.
- Penrose, Edith Tilton, The Economics of the International Patent System, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1951.
- Schmidt-Szalewski, Joanna / Pierre, Jean-Luc, Droit de la propriété industrielle, 3^e édition, Litec, 2003.

중세 이후 특허법제사에 관한 연구

Silberstein, M., Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien, Zürich 1961.

Treue, W., Die Entwicklung des Patentwesens im 19. Jahrhundert in Preußen und im Deutschen Reich in: Coing, H./Willhelm, W. (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, Bd. IV, 1979.

竹田和彦, 特許の知識, ダイヤモンド社, 2006.

[주제어] 최초의 특허법, 베니스공화국, 영국의 독점조례, 특허반대,
특허중시

<ABSTRACT>

A Study on the Patent History since the Middle Ages

Han, Ji-Young

This article handles with the patent history since the Middle Ages, which especially includes Venetian Patent Act as the oldest patent law in the world as well as the Statue of Monopolies in England called as the Magna Charta of the patent law. The prerogative right to grant monopolies to inventions in Europe was indiscretely given by the Crown for the purpose of supporting its own poor finances, but afterwards began to grant monopolies according to substantial law on patent. In 1850 to 1873 free trade movement which did not acknowledge monopolies in market was against pro patent. However, aggravation of the economy in Europe those days brought patent advocates again to provide opportunities to deliver a counterattack to those who asserted anti-patent, even abolition of the patent system. In the end, patent advocates successfully defeated anti-patent. Since then many countries have adopted the policy establishing their own patent acts.

[Keyword] The First Patent Act, Patents of the Venetian Republic, Statute of Monopolies of England, Anti-Patent, Pro-Patent.